

1503921-33.2021.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/06/2022

... a ré e o adolescente confessaram o tráfico. O réu negou. Disse que a ré lavava roupas para ele, mas uma equipe da DISE acompanhou as buscas e eles tinham notícias recentes de que o acusado também estava envolvido com o tráfico. Receberam informações de um usuário que não quis se identificar no sentido de que a ré praticava o tráfico. As diligências investigativas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503921-33.2021.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503921-33.2021.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2259829/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 20425457 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2700/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2259829 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2259829 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 2700/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLA CRISTINA DOMINGUES PAES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

CARLA CRISTINA DOMINGUES PAES e ROBERT WILLIAMS DE SOUZA SILVA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", c.c. art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, na tarde de 22 de setembro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Nestor Rodrigues Pedroso, número 115, Vila Jardim, neste município e Comarca de Avaré, com o envolvimento do adolescente Alexandro Duarte Belalva, tinha em depósito 04 (quatro) porções de maconha e meio tijolo da mesma droga, com peso aproximado de 405,35 (quatrocentos e cinco gramas e trinta e cinco miligramas) e outras 20

(vinte) porções de crack no bolso do adolescente, com peso de 3,10g (três gramas e dez centigramas), conforme laudo de constatação provisória a fls. 49/55 e laudo de exame químico-toxicológico a fls. 149/154, substância que causa dependência, o que fazia em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS). Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/159. Por decisão proferida em 23 de setembro de 2021, foi concedida a liberdade provisória mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP em relação à ré Carla e, a prisão em flagrante do réu Robert foi convertida em prisão preventiva (fls. 124/127). Alvará de soltura cumprido a fls. 136/137 e mandado de prisão cumprido a fls. 139/140. A denúncia foi oferecida em 07 de outubro de 2021 e os réus, notificados a fls. 174 e 188, ofereceram Defesa Prévia a fls. 191 e 217. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 01 de fevereiro de 2022, oportunidade na qual também foi designada audiência de instrução e julgamento (fls. 223/225). Em audiência, foram inquiridas 03 testemunhas de acusação e os réus interrogados (fls. 345/346 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia (fls. 349/354). A douta Defesa da ré Carla, por sua vez, pleiteou pela desclassificação do delito para uso próprio. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da lei de drogas, pela substituição da pena por restritiva de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 357/362). A Defesa do corréu Robert, pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou pela desclassificação do delito para o crime de porte de drogas e, em caso de eventual condenação, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal, pelo reconhecimento da causa de diminuição do §4º do art. 33 da lei de Drogas, bem como pela fixação do regime aberto e substituição da pena por restritivas de direitos (fls. 366/379).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "havia notícias do envolvimento dos denunciados com a prática do tráfico de drogas. Mediante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos número 1503900-57.2021.8.26.0073, a DISE Avaré se dirigiu até a residência da denunciada. No local se encontravam CARLA, ROBERT e o adolescente Alexandro. CARLA e ROBERT tinham em depósito em uma mureta, próximo ao local em que se encontravam sentados, quatro porções de maconha e, no corredor do imóvel, meio tijolo da mesma droga. Ainda, em uma cômoda no quarto de CARLA foi encontrado um pote com resquícios de crack. Com Alexandro foram localizadas 20 (vinte) porções de crack e R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) em espécie e notas diversas, sendo o adolescente apreendido em auto próprio. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro".

Finda a instrução processual, à luz da prova produzida, a denúncia procede integralmente.

A materialidade delitiva restou configurada pelo auto de prisão em flagrante a fls. 01/02, auto de exibição e apreensão a fls. 40/41, laudo de constatação provisória a fls. 49/55, fotografias a fls. 56/60, boletim de ocorrência a fls. 61/68, comprovante de depósito a fls. 142/144, laudo toxicológico a fls. 149/154, bem como por toda a prova oral produzida em juízo.

A autoria delitiva, de igual modo, também restou inconteste e recai sobre os réus. A testemunha de acusação Fernando Mantovani Tavares, policial civil, em juízo, disse "tinham denúncias de que a ré estava praticando tráfico de drogas na residência. Foi expedido mandado de busca e no local foram encontrados os réus, em companhia do adolescente, drogas e dinheiro. Informalmente, a ré e o adolescente confessaram o tráfico. O réu negou. Disse que a ré lavava roupas para ele, mas uma equipe da DISE acompanhou as buscas e eles tinham notícias recentes de que o acusado também estava envolvido com o tráfico. Receberam informações de um usuário que não quis se identificar no sentido de que a ré praticava o tráfico. As diligências investigativas confirmaram as informações da forma como obtidas com o

usuário. Não há notícias de que a ré lavava roupas para terceiros, pelo contrário, o local é conhecido nos meios policiais por ser ponto de tráfico e não tinham nenhuma informação que ela lavava roupa".

A testemunha de acusação Valdemir Alcides Matias, policial civil, judicialmente, corroborou a versão de seu colega policial. Acrescentou "que Robert foi preso em flagrante por tráfico de drogas no mesmo bairro meses antes dos fatos aqui tratados. Disse que no quintal da casa estavam Carla, Robert e Alexandre. Em buscas, próximo onde eles estavam 4 porções de maconha. No corredor, o tijolo de maconha e no quarto da Carla pote com resquícios de crack. Em busca pessoal, no bolso do adolescente 20 pedras de crack e R\$ 180,00 reais em dinheiro em notas diversas. Com Carla também encontraram R\$ 80,00 e com Robert R\$ 212,00. Falou que os réus não deram nenhuma justificativa sobre o dinheiro encontrado".

O adolescente Alexandro Duarte Belalva, judicialmente, contou "que foi até a residência da ré para fazer refeições e que tinha drogas consigo. Falou que não sabia se os réus tinham drogas naquele dia. Falou que conhece os acusados pois moram no mesmo bairro e que, pelo que sabe, o Robert levou roupas para a Carla lavar".

O réu Robert, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados na denúncia. Disse "que levou suas roupas para a ré lavar, que ela fazia bicos lavando roupas. Falou que estava na residência da ré usando drogas e que estava com dinheiro em espécie para levar para sua esposa. Disse que é amigo de Alexandro e que não estavam juntos antes de se encontrarem na residência da acusada".

A ré Carla, em seu interrogatório judicial, admitiu a traficância. Disse "que vendia drogas para manter o vício, mas que não sabia das 400 gramas de maconha encontrado na casa. Nada disse sobre o dinheiro. Falou que o réu e o adolescente também eram usuário".

Pois bem, as provas colhidas em juízo apontam para a ilícita mercancia praticada pelos réus. A tipificação do crime de tráfico de drogas, in casu, extrai-se do local da prisão (conhecido ponto de venda de drogas), das circunstâncias da prisão, da quantidade de droga apreendida (04 porções de maconha, meio tijolo também de maconha e 20 pedras de crack), do modo pelo qual estava acondicionada, bem como a localização de dinheiro, cuja origem lícita os réus não comprovaram.

Outrossim, é dos autos que após concurso policial visando reprimir o crime de tráfico de drogas no bairro Vila Esperança, coube aos investigadores o cumprimento do mandado judicial de busca domiciliar expedido por este juízo (processo 1503900-57.2021.8.26.0073), na residência da corré Carla, tendo em vista que denúncias davam conta de que o local era ponto de venda de drogas e que a mesma atuava na companhia de outros vendedores de drogas, inclusive adolescentes. E assim é que, realizada a busca no local, foram localizadas as drogas descritas na denúncia, além de quantia considerável de dinheiro.

Com efeito, verifico que, conquanto o corréu Robert tenha negado sua participação no delito, sua negativa nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade. Ora, a inocência por ele invocada não tem amparo das provas coligidas, pois não há qualquer dúvida de que a sua intenção era a de entregar a droga apreendida ao consumo de terceiros até porque, a quantidade de entorpecente apreendido é incompatível com o uso momentâneo. E aqui, ressalte-se que a versão por ele dada é absolutamente fantasiosa, não merecendo o mínimo de credibilidade, vez que pueril e absolutamente divorciada do conjunto probatório, mormente porque sequer a própria corré Carla mencionou em seu interrogatório que lavava roupas para Robert.

Já a confissão parcial da corré Carla admitindo que praticava sozinha o tráfico de drogas como uma forma de manter seu vício revela, tão somente, mais uma tentativa inexitosa de livrar o corréu Robert, bem como reduzir significativamente sua pena almejando o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art 33.

Nesse contexto, o conflito de posição entre Carla e Robert mostrou que estavam mancomunados na venda de drogas sendo que suas versões, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceram de todo isolada no contexto probatório, já que

nada produziram, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação. Nesse sentido: "... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Ressalte-se, ainda, que conquanto o adolescente Alexandro tenha negado seu envolvimento com o crime, certo é que, nos autos do processo infracional nº 1503920-48.8.26.0073, em trâmite perante a Justiça da Infância e Juventude desta Comarca, comprovou-se sua participação no delito, tendo-lhe sido aplicada a medida sócio-educativa de internação por prazo indeterminado.

Destaco, ainda, que os depoimentos prestados pelas testemunhas, da fase inquisitiva à judicial, foram firmes e seguros, não se vislumbrando qualquer interesse em acusar ou prejudicar os réus, merecendo plena credibilidade a versão por eles ofertada. Não se pode conceber a justificativa rasa de que os policiais permanecem perseguindo cidadãos e atribuindo-lhes a propriedade de quantia tão grande de entorpecente com o único fim de prejudicar o réu. Nesse sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846) (g.n.).

De mais a mais, ressalto que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

"... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano." (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

Neste íterim, a alegação da corré Carla de que é usuária de drogas, por si só, não retira a convicção de que também traficaria. Prova do alegado vício era ônus que lhe pertencia do qual, porém, não se desincumbiu. Além do mais, pode coexistir, na mesma pessoa, a figura de traficante e usuário. O fato de ser usuário de substância entorpecente não obsta ao reconhecimento da figura de traficante. Ao contrário, é natural que ambas as condições, a de usuário e a de traficante coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilitar-se-á o emprego na compra, para que o vício possa ser sustentado. Neste sentido, decisão da E. Corte Bandeirante:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Impetração visando a absolvição pela fragilidade probatória Pedido final de desclassificação ou substituição da pena.

IMPOSSIBILIDADE. Presentes a autoria e a materialidade - Reconhecimento do tráfico pelas circunstâncias da ocorrência - Usuário também pode ser traficante Guardas civis que visualizaram o momento em que o apelante jogou as drogas ao chão Inviável o aumento da redução e a substituição da pena - Recurso não provido. TJ-SP -

Apelação: APL 00000372620128260125 SP 0000037-26.2012.8.26.0125.

Julgamento:12/08/2014 (grifo nosso)

Assim sendo, examinando o arcabouço probatório emergente dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ademais, inobstante a corré Carla afirme que as drogas eram para uso próprio, em seu poder não foram encontrados apetrechos ou instrumentos utilizados para o consumo de drogas, ressaltando a finalidade mercantil dos entorpecentes.

De igual modo, a causa especial de aumento descrita no inciso VI (envolver adolescente) do art. 40 da lei de Drogas está devidamente comprovada nos autos tanto que, como já dito anteriormente, o adolescente respondeu a processo infracional tendo-lhe sido aplicada a medida sócio educativa de internação. Neste ínterim, ressalte-se ser absolutamente fantasiosa as alegações do menor no sentido de que estava ali para usar drogas com os réus, seja pela quantidade elevada de entorpecente encontrado, seja pelo dinheiro cuja origem lícita não se comprovou. Desta feita, merece reprovação maior a conduta perpetrada pelos réus, eis que, em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral, utilizaram-se do seu relacionamento com o adolescente, disseminando droga em sua vida e atrelando-o ao comércio espúrio de entorpecentes em detrimento de uma vida correta, pautada pelos estudos e trabalho honesto, mostrando a ele lucro fácil na tentativa de lhe desvirtuar do caminho que deve percorrer os cidadãos de bem.

De outra feita, a defesa não explicou e não logrou refutar as assertivas minuciosas dos depoentes e não arrolou testemunhas que amparassem suas ressalvas. Não indicou motivos concretos e plausíveis para falsa incriminação. Assim, o contexto fático revela, de maneira indubitosa, que os réu praticavam o comércio de entorpecente, sendo de rigor a condenação.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus CARLA CRISTINA DOMINGUES PAES e ROBERT WILLIAMS DE SOUZA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. Resta dosar a pena pelo critério trifásico adotado pelo Código Penal. Em relação à ré Carla Cristina, na primeira fase da dosimetria da pena, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que a acusada é primária (F.A. e certidões a fls. 247/248 e 253/254), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, deixo de reconhecer a atenuante confissão eis que filio-me ao entendimento de que "a confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator, pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal (RJDTACRIM 31/84)". Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por outro lado, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa ou de que esteja presente a habitualidade delitiva. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do

artigo 33, §2º, do Código Penal. Confirma-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55 do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo à ré o direito de recorrer em liberdade.

Já em relação ao corréu Robert Willians, na primeira fase, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta antecedentes criminais (F.A. e certidões a fls. 249/252 e 255/256) e, tendo já cumprido pena privativa de liberdade, voltou a delinquir. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a praticar novo delito. Sobressai-se, no caso em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da lei 11.343/06. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica da ré (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, ausentes quaisquer das circunstância agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) da Lei 11.343/06, razão pela qual aumento a pena em 1/6 (um sexto), atingindo o patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Muito embora não exista nenhuma notícia e mesmo prova nos autos de que o réu pertencia a alguma associação criminosa, entendo que a condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas (fls. 255/256) revela a conduta voltada à prática de atividades criminosas. Ademais, a prova dos autos indica que fazia o tráfico com certa frequência e de droga de fácil disseminação e com alto poder de vício ("crack"). Tal circunstância impede a aplicação do benefício legal do parágrafo quarto do artigo 33 da Lei de Drogas. Nesse sentido: "Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante por tráfico de drogas. Liberdade Provisória: inadmissibilidade. Decisão que manteve a prisão. Participação em organização voltada para o tráfico de entorpecentes e grande

quantidade de droga apreendida: circunstâncias suficientes para a manutenção da custódia cautelar. Aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da lei n. 11.343/06 e de substituição da pena: improcedência. Redução da pena inviável na via estreita do habeas corpus. Ordem denegada. [...] 6. Os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. 7. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas. [...]” (STF HC 109.236/SP Rel. Min. Cármen Lúcia j. 13.12.11 DJU 14.23.12 – destaquei do original). Sendo assim, fixo em definitivo a pena a cumprir de 6 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL. A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública. É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada. Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, “O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento” (“Código de Processo Penal Comentado”, 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciosos para decidi-la. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente

possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04 anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Outrossim, porque o réu respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber sentença condenatória. Recomende-se. Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República, oficie-se ao I.I.R.G.D., fornecendo informações sobre a condenação do réu, e providencie-se o necessário para o cumprimento da sanção penal imposta. Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias e efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 28 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA